

1505605-89.2021.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... a ser concedido aos condenados pelo crime de tráfico, se preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Seguindo esse posicionamento, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo e do STJ:

"Tráfico de entorpecentes. Acusado flagrado parado no meio da rua em local conhecido pelo comércio espúrio. Apreensão de 41 porções de cocaína, com peso de 33,30 gramas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505605-89.2021.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505605-89.2021.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2110417/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 17495572 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 1062/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2110417 - DEL.POL.SALTO, 1062/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

CARLOS EDUARDO DAMASCENO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu CARLOS EDUARDO DAMASCENO por infração no art. 33, "caput" da Lei Federal nº 11.343/06 c.c. o art. 40, inciso III (nas imediações de recinto onde se realiza diversões de qualquer natureza) e com o art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, em tese, no dia 22 de abril de 2021, por voltas das 19h29min, na praça situada na Rua São Tomé, nº 01, Jardim Nova Era, nesta cidade e comarca de Salto/SP, o acusado, em ocasião de calamidade pública, nas imediações de recinto onde se realiza diversões de qualquer natureza, guardava e trazia consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito, 28 (vinte e oito) porções de "cocaína", com peso líquido de 17,43g (dezesete gramas e quarenta e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 16 de junho de 2021 (fls.82-89).

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls. 112-118).

A denúncia foi recebida em 24 de novembro de 2021 (fls.123-126) e o réu citado.

Os pedidos de instauração de incidente de dependência toxicológica e preliminar de justa causa foram apreciados e rejeitados pela decisão de fls. 123-126, que transitou em julgado.

Durante a instrução processual o réu foi interrogado e foram inquiridas três testemunhas arroladas pela acusação e duas arroladas pela defesa.

Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, a agravante da menoridade e alternativamente que o acusado possa recorrer em liberdade e .

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01-02), boletim de ocorrência (fls. 03-04), auto de exibição e apreensão (fl 08-09), auto de constatação preliminar (fl.07) e laudo de exame químico toxicológico (fls.76-78), bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

Os guardas municipais, Robson Silveira Barbosa e Denis Fernando Froes, testemunhas de acusação, foram uníssomos ao relatar em juízo que estavam em patrulhamento, quando avistaram o réu saindo de uma praça e entregando algo para uma pessoa. O réu retornou rapidamente para a praça e a outra pessoa entrou em um veículo. Após abordagem em revista pessoal, com a pessoa no interior do veículo foram localizados 02 porções de cor rosa, com substância análoga a cocaína. Questionado sobre a procedência da droga, disse que havia comprado do acusado pela quantia de R\$ 20,00. Após revista pessoal em Carlos, localizou-se no bolso traseiro da calça a quantia de R\$ 150,00 e ainda um aparelho celular motorola. Inquirido, disse que estava naquele local realizando o tráfico de drogas e ainda indicou que em um outro ponto da praça, numa árvore, existiam mais entorpecentes escondidos, logrando êxito em localizar mais 26 "eppendorfs" de substância análoga a cocaína, em embalagem idêntica a que foi localizada antes.

A testemunha Thiago Gonçalves Lobo, relatou que é usuário de entorpecente. Na data dos fatos, comprou 02 porções de cocaína do réu. A viatura chegou na hora da negociação e os guardas realizaram a abordagem. Não conhecia o acusado.

O réu confessou os fatos a ele imputados. Afirmou, em resumo, que seu primo, Gustavo Henrique, disse que iria sair e lhe deu uma de pó para vender. Thiago chegou e o réu vendeu droga para ele, nesse momento a GCM chegou.

A confissão do réu foi satisfatoriamente corroborada pelos depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo, guardas municipais que participaram da ocorrência. Esses testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria do crime de tráfico.

O réu guardava e trazia consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito, 28 (vinte e oito) porções de "cocaína", com peso líquido de 17,43g (dezesete gramas e quarenta e três centigramas), individualmente embaladas e prontas para a entrega a consumo e fornecimento a terceiros, denotando-se o intuito de comercialização. Além disso, o acusado foi preso em flagrante após os guardas presenciarem a negociação ilícita, ratificado pelo usuário Thiago Gonçalves Lobo, não sendo crível que tais pessoas mentissem apenas para prejudicar o réu.

Acrescento que as porções de cocaína recuperadas em poder de Thiago eram semelhantes àquelas encontradas no local dos fatos, sendo que Thiago confirmou haver adquirido a droga do acusado.

As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Além disso, cuida-se de crime permanente e guardas municipais podem realizar prisão em flagrante. Finalmente, não há qualquer indício de prova que autorize concluir que os guardas tenham mentido para prejudicar o réu. Nesse sentido tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: Tráfico ilícito de entorpecentes. Preliminares afastadas. Ilicitude de provas por

terem sido obtidas por guardas civis municipais não constatada. Inteligência do artigo 144, § 8º, da CF, regulamentado pela Lei 13.022/2014, em interpretação conjunta com o artigo 301, do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita apta a justificar o ingresso no imóvel. Réu flagrado ao sair de ponto conhecido de comércio espúrio, sendo abordado e apreendido em seu poder a quantia injustificada de R\$ 40,00. Em incursão por viela próxima ao local, os agentes estatais, após iluminarem o imóvel que estava com a porta aberta, avistaram uma sacola preta, contendo, em seu interior, 65 porções de cocaína, com massa líquida de 26,62 gramas, e 90 porções de maconha, com peso líquido de 220,67 gramas. Cômulo pertencente ao acusado. Violação não constatada. Entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral (tema 280). Pleito absolutório Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais. Negativa do réu isolada. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Reforma das penas. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da quantidade de droga. Volume que não justifica maior reprovabilidade da conduta. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Exclusão da agravante da calamidade pública. Aplicação do redutor à fração máxima. Penas finalizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 1503301-54.2020.8.26.0526; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

TRÁFICO ILÍCITO E ASSOCIAÇÃO. Recursos defensivos. PRELIMINARES. Pedido de liberdade provisória. Prejudicado pelo julgamento Colegiado. Suposta prova lícita. Desnecessidade de mandado em se tratando de crime permanente. Prisão por Guarda Municipal. Possibilidade. Inteligência da Lei nº 13.022/14 (Estatuto das Guardas Civis). Rejeição. ART. 33, CAPUT. Absolvição Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. ART. 35, CAPUT. Reversão da condenação. Viabilidade. Não demonstração de estabilidade e caráter duradouro. Mero concurso de agentes. DOSIMETRIA. Redução do aumento na primeira etapa de DOUGLAS. Afastamento da reincidência (trânsito em julgado afastado pelo HC nº 2290149-29.2020.8.26.0000, j. 19/3/2021, 8ª Câmara, TJSP). Manutenção da agravante da calamidade. Reconhecimento da menoridade relativa de DENILSON. Penas de DOUGLAS e DENILSON reduzidas. Inaplicabilidade da benesse do art. 33, § 4º. Regime fechado preservado. ISENÇÃO DAS CUSTAS. Inviabilidade. Inteligência da Lei nº 1.060/50 e Lei Estadual nº 11.608/03. PROVIMENTO PARCIAL. (TJSP; Apelação Criminal 1501786-81.2020.8.26.0526; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021).

Antes de iniciar a fixação da reprimenda, em respeito ao princípio da individualização das penas, artigo 5º, inciso VLVI, da Constituição Federal, se fazem necessários alguns esclarecimentos acerca dos critérios doutrinários e jurisprudenciais adotados por este julgador durante a dosimetria. No que se refere à agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", inexistem elementos que indicam que o réu tivesse se aproveitado da situação de calamidade pública para praticar o delito. Com efeito, o estado de emergência sanitária não facilitou a execução da conduta delituosa. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação.

Conforme julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "O contexto de calamidade pública, ainda que decretado pelo Poder Público, não é apto à caracterização da agravante, no caso presente, a não ser que, v. g., se estivesse em cenário particularizado, como a falsificação de uma vacina ou o descumprimento de medida sanitária preventiva." (Apelação Criminal nº 1501808-87.2021.8.26.0047, Relato: Guilherme de Souza Nucci.)

Essa é a maciça posição do Superior tribunal de Justiça, a saber: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE

AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal nº 1501808-87.2021.8.26.0047 -Voto nº 26736 8 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. 2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal nº 1501808-87.2021.8.26.0047 -Voto nº 26736 9 QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

Deve ser afastada a causa de aumento relativa ao local onde o crime foi cometido, afinal os entorpecentes foram apreendidos em praça pública (fls. 88-89), local que além de não constar no rol da lei de regência, tampouco se enquadra como "recinto onde se realizam diversões de qualquer natureza". Ainda, não restou demonstrado que o local conta com quaisquer atrativos que ensejem a aglomeração de grande número de pessoas. Pelo contrário, os guardas municipais afirmaram que a praça é conhecida por ser ponto de tráfico de drogas. Nesse sentido, já julgou o STJ e o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PREQUESTIONADA NA ORIGEM. RECONSIDERAÇÃO. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. PRAÇA PÚBLICA. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. AGRAVO PROVIDO. 1. Prequestionada a matéria perante o Tribunal de origem, deve ser conhecido o recurso especial. 2. A prática de crime de tráfico de drogas em praça pública, por si só, não atrai a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, porquanto não prevista em lei, sendo vedado o uso da analogia in malam partem. 3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e dar-lhe provimento a fim de reduzir a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, mantido o regime fechado (STJ. AgRg no AREsp 1495549/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020).

"Tráfico de drogas. Apelos defensivos e do Ministério Público. Pleito da defesa que busca a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; a fixação do regime aberto e o direito de recorrer em liberdade. Pleito Ministerial que busca o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista pelo artigo 40, III, da Lei de Drogas. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Réu confesso. 2. Dosimetria da pena que merece reparos. Cabível o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Atos infracionais anteriores não se prestam a revelar o envolvimento em atividades criminosas. Concessão do benefício. Redução em 2/3. Afastamento da causa de aumento do artigo 40, III, da Lei de Drogas. Rol taxativo que não contempla "praças públicas". Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Fixação do regime aberto com expedição de alvará de soltura clausulado. (TJSP; Apelação Criminal 1501162-16.2019.8.26.0575; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Pardo - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 01/04/2020)".

O Plenário do STF, no julgamento dos habeas corpus nº 112.776 e nº 109.193,

consolidou entendimento segundo o qual "configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para se fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)".

Importante salientar que as causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual.

Portanto, se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário e de bons antecedentes, sem ligações criminosas, com pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior diminuição (ex.: dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base. O contrário também se dá. Percebendo enorme quantidade de drogas, ainda que em poder de traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações com o crime organizado, pode reservar tal circunstância para a utilização na diminuição da pena.

O legislador não estipulou quais seriam, apenas mencionando dever o magistrado reduzir a pena de um sexto a dois terços. É lógico que há de existir o cuidado de evitar "bis in idem". Na hipótese analisada, a quantidade apreendida é pouco expressiva: 17,43 g (dezessete gramas e quarenta e três centigramas) de cocaína, o réu é primário e não integra organização criminosa, tudo a justificar a incidência da causa de diminuição em grau máximo. Nesse sentido, tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico - Suficiência de provas - Manutenção da condenação. Penas - Aumento das básicas por diversidade e natureza dos entorpecentes - Exclusão - Quantidade pouco expressiva - Espécie de um dos tóxicos, por si só, não autoriza exasperação - Critérios cumulados do art. 42 da Lei 11.343/06. Penas - Fixação no piso - Inviável maior diminuição por atenuante - Súmula 231 do STJ. Art. 40, III, da Lei 11.343/06 - Necessidade de demonstração de interesse em propagar o uso de tóxicos entre aqueles que circulam pelos lugares enumerados - Não incidência. Redutor - Cabimento - Réu primário, menor, confesso e sem antecedentes - Redutor máximo - Quantidade não significativa de droga, considerado o peso total. Regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Possibilidade. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 1502170-63.2019.8.26.0628; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapevi - Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/11/2021; Data de Registro: 09/11/2021)

TRÁFICO DE DROGAS. Conduta de ter em depósito, para fornecimento a consumo de terceiros, 56,8g de maconha, 32,6g de cocaína e de 8,6g de cocaína na forma de crack. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial somada à prova testemunhal, consistente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. Natureza, diversidade, quantidade e modo de acondicionamento. Condenação mantida. PENA. Causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em sua fração máxima. Admissibilidade. Réu primário e de bons antecedentes. Ausência de prova da dedicação a atividades criminosas. Incidência do redutor máximo por conta da pequena quantidade e das circunstâncias judiciais favoráveis. Concretização em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa.

SUBSTITUIÇÃO da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Precedente do STF. Fixação do regime aberto. Apelo provido para esse fim. (TJSP; Apelação Criminal 1500316-10.2020.8.26.0366; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mongaguá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/02/2021; Data de Registro: 17/02/2021)

Finalmente, a partir do julgamento do HC 97.256 pelo STF, quando foi declarada incidentalmente a parcial inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 33 e do artigo 44 da Lei de Drogas, o benefício da substituição da pena passou a ser concedido aos condenados pelo crime de tráfico, se preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Seguindo esse posicionamento, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo e do STJ:

"Tráfico de entorpecentes. Acusado flagrado parado no meio da rua em local

conhecido pelo comércio espúrio. Apreensão de 41 porções de cocaína, com peso de 33,30 gramas, além de R\$ 155,00. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Redutor reconhecido, mas aplicado em grau menor. Tráfico privilegiado concedido em sua máxima extensão. Regime aberto. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Parcial provimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 1500864-37.2019.8.26.0603; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA IMPOSTA PARA UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. TIPO PENAL AO QUAL É COMINADA PENA DE MULTA CUMULATIVA COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRIORIDADE À SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ANALOGIA À SÚMULA 171/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Hipótese na qual a instância ordinária, de forma motivada, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a natureza e a variedade das drogas apreendidas (89 micropontos de LSD e 30 comprimidos de ecstasy), exclusivamente, na terceira etapa da dosimetria da pena, para fazer incidir a minorante em 1/2, o que não se mostra desproporcional. Precedentes STJ e STF. 3. O art. 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, nas condenações superiores a 1 ano, por duas restritivas de direitos ou por uma restritiva de direitos e multa, cabendo ao Magistrado processante, de forma motivada, eleger qual medida é mais adequada ao caso concreto. Salvo se evidenciada manifesta desproporcionalidade, deve ser mantida a pena restritiva de direitos imposta ao réu. 4. O preceito secundário do crime pelo qual o paciente foi condenado (art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006) já estabelece a cumulação da pena de multa com a pena privativa de liberdade, de modo que se deve privilegiar na substituição a escolha da pena restritiva de direito, em observância à Súmula 171/STJ. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 643.390/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021). Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu é primário, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime não podem ser valorados negativamente, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravante do art. 61, inciso II, alínea "j" e presentes as atenuantes da menoridade e confissão, porém, mantenho a pena no mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ.

Ausentes causa de diminuição e aumento, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Considerando a primariedade e o não envolvimento da ré com nenhuma organização criminosa, com fundamento no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, reduzo a pena em 2/3, obtendo a pena final de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da quantidade das penas aplicadas, as circunstâncias judiciais favoráveis e sendo o réu primário, o regime é aberto (artigo 33, §2º, alínea 'c' e §3º, do Código Penal).

Atendidas as condições previstas no art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, com os fundamentos antes apontados para reconhecimento da inconstitucionalidade da norma de vedação, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na

prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu CARLOS EDUARDO DAMASCENO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei de Tóxicos, sendo a pena privativa de liberdade substituída nos moldes determinados acima.

Faculto a interposição de recurso em liberdade, diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e regime aplicados.

Arcará o réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo.

Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos .

Publique-se e intime(m)-se.

Salto, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA